

VINCENZO ARANGIO-RUIZ

**INSTITUCIONES
DE
DERECHO ROMANO**
FRANJA
MORADA

Depalma

FRANJA MORADA

RANGIO-RUIZ

INSTITUCIONES
DE
DERECHO
ROMANO

FRANJA
MORADA

Depalma

4000

271

FRANJA MORADA

FRANJA MORADA

INSTITUCIONES DE DERECHO ROMANO

**FRANJA
MORADA**

FRANJA MORADA

VINCENZO ARANGIO-RUIZ

Profesor ordinario de la Universidad de Roma

INSTITUCIONES DE DERECHO ROMANO

Traducción de la 10ª edición italiana

por JOSÉ M. CARAMÉS FERRO

Profesor titular de Derecho Romano en la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Prólogo

por el Dr. EDUARDO R. ELGUERA.

Reimpresión inalterada



EDICIONES *Depalma* BUENOS AIRES

1986

FRANJA MORADA

ISBN 950-14-1086-6



EDICIONES *Depalma* BUENOS AIRES

Talcahuano 494

*Hecho el depósito que establece la ley 11.723. Derechos reservados.
Impreso en la Argentina. Printed in Argentina.*

PRÓLOGO

I. — Estábamos retrasados en lo que se refiere a la traducción de obras de derecho romano de la moderna y brillante escuela italiana. No disponíamos nada más que de las versiones españolas de la *Historia del derecho romano* y las *Instituciones* de BONFANTE y la *Historia del derecho romano* de ARANGIO-RUIZ; aparte de la edición mejicana del cursillo sobre procedimientos de este último autor, desarrollado en El Cairo y publicado bajo el nombre de *Las acciones en el derecho privado romano*. Es cierto que muchos estudiantes conocen la lengua italiana, pero para la mayoría, aunque la entiendan, les resulta fatigosa su lectura.

Mientras tanto, es imprescindible para los alumnos estudiar en obras de esa escuela. Sus doctrinas dominan hoy el mundo romanista. La renovación de las investigaciones de la ciencia jurídica romana, que se está realizando en Italia, nos muestra el derecho de la época clásica en toda su pureza, no sólo porque nos pone en presencia de los textos de los grandes jurisconsultos libres de interpolaciones, sino también porque la epigrafía y la papirología nos hacen ver la vida de esos principios jurídicos en la realidad. De esta manera se destaca nítidamente la evolución operada, sus orígenes rudos en tiempos de los quirites, la elaboración de las normas básicas en la época clásica, hasta su perfeccionamiento y estatificación en el *Corpus iuris*. Aunque esto último relativamente, porque con ello no se marca más que una etapa, ya que la labor jurídica de la Edad media y de la época moderna no es más que una adaptación de aquel derecho, conforme a las nuevas necesidades y costumbres.

Por eso la cátedra argentina, en estos últimos tiempos, siguió la huella marcada por la doctrina italiana, exponiendo y sosteniendo sus conclusiones, dando a conocer sus investigaciones, su crítica de textos y los principios que surgen de ellos.

Los alumnos quieren conocer directamente la obra de aquellos grandes maestros que nombramos desde la cátedra. Los estudiosos acuden a la bibliografía que les indicamos en su idioma vernáculo, pero la mayoría consulta la que le basta para satisfacer su curiosidad intelectual, la síntesis de los manuales, que para mayor comodidad desea que estén escritos en su propio idioma: sólo disponen de las *Instituciones* de BONFANTE, obra maestra y que merece nuestro más grande elogio, pero que aparte de exponer puntos de vista muy personales, tiene el inconveniente de haber sido editada en España, lo que a veces dificulta su adquisición.

Es por eso que, con nuestro colega doctor CARAMÉS FERRO, pensamos en la traducción de las *Instituciones* del profesor ARANGIO-RUIZ, con cuyas líneas generales concordaba en gran parte la enseñanza de la cátedra y cuya obra sobre *Historia del derecho romano* había encontrado excelente acogida entre los estudiantes en su versión castellana. Esta idea se concretó cuando el maestro visitó la Facultad en 1948, quien complacido autorizó esta traducción, que llevó a cabo el profesor CARAMÉS FERRO en forma admirable.

II. — El maestro VINCENZO ARANGIO-RUIZ, que iniciara muy joven la enseñanza en Perugia, fué durante muchos años profesor de la Universidad de Nápoles, hasta su designación como catedrático de *Instituciones* en la de Roma.

Durante todo este tiempo, aparte de la enseñanza universitaria, su actividad no ha descansado como investigador de papiros e inscripciones, trabajador infatigable en exégesis y crítica de textos, autor de monografías, ensayos y obras de enseñanza. Como si esto fuera poco, ante el requerimiento de su patria, tuvo que dejar su grata, paciente y serena labor de investigador, erudito y expositor, para ocupar el Ministerio de Instrucción Pública en horas cruciales, para luego retornar a su trabajo universitario, con una actividad paralela de actuación en congresos jurídicos, conferencias y cursos en el extranjero.

En 1933 le correspondió el mérito insigne de descubrir en El Cairo un papiro con unos fragmentos de las *Institutas* de GAYO, conteniendo unas páginas de una copia del siglo IV o V, es decir, anterior a la del palimpsesto de Verona y en mejor estado, que posiblemente formaba parte de un codice de lujo prepa-

rado para algún profesor de Alejandría. De este descubrimiento nos informa en su monografía *Frammenti di Gaio*, donde analiza los fragmentos descubiertos y señala su importancia para el conocimiento del derecho romano, con relación a la sociedad, la indivisión, la extinción de las obligaciones y las acciones de la ley.

Posteriormente descubre con VOGLIANO una inscripción de la época Flavio-Trajana, de fecha incierta, pero indiscutiblemente del siglo I, conteniendo tres rescriptos referentes a cuestiones municipales, que publica en "Atheneum" en 1942.

Además de su interesante *Historia del derecho romano*, tan llena de observaciones agudas, conocida por todos los estudiantes, y de las *Instituciones* que ahora se traducen, ambas dedicadas a la enseñanza, el profesor ARANCIO-RUIZ es autor de una cantidad de monografías, ensayos y artículos sobre derecho romano, siendo de notarse especialmente sus trabajos sobre papirología y epigrafía, que han aclarado muchos aspectos referentes a los medios de prueba en aquel derecho. A este respecto cabe recordar su monografía sobre *Les tablettes d'Herculanum* y la conferencia que sobre el mismo asunto dió en nuestra Facultad.

Sería prolijo mencionar toda su obra, pero además de los citados no podríamos dejar de señalar sus estudios referentes a libros atribuidos a GAYO, *Sul liber singularis regularum* y *Ancora sulle Res cottidianae*; sus monografías sobre procedimiento: *Le formule con demonstratio e le loro origine* y *L'exceptio in diminuzione della condanna*; sus estudios sobre papirología: *Persone e famiglia nel diritto dei papiri*, *Applicazione del diritto giustiniano in Egitto*; por último su trabajo *Le genti e la città* y su interesante artículo sobre *La Legislazione di Augusto*.

Como lo acabamos de recordar, en 1948 estuvo entre nosotros y pronunció varias conferencias en la Facultad de Derecho, publicando en ésta su artículo sobre *El testamento romano como documento dispositivo*.

El autor de la obra traducida, además de ser uno de los más grandes maestros contemporáneos del derecho romano, tiene esa vinculación con la Argentina y es un gran amigo de ella.

III, — La obra traducida es un exponente típico de la moderna escuela italiana y un modelo como manual de instituciones romanas.

El profesor ARANGIO-RUIZ la publicó en Nápoles bajo el nombre de *Corso di istituzioni di diritto romano* en dos volúmenes, apareciendo el primero en 1921 y el segundo en 1923, publicándose una segunda edición en 1927; luego revisa su obra que se edita en un volumen con el nombre actual de *Istituzioni di diritto romano* en 1934; más tarde, en la cuarta edición de 1937, reconstruye la exposición de la doctrina del derecho sucesorio. Su éxito ha sido tan notorio que desde entonces se han impreso seis ediciones más, siendo la décima la que ha servido para la presente traducción.

El plan de la obra es el de la dogmática moderna, seguida por la mayoría de los tratadistas actuales, especialmente los italianos, alemanes y españoles y también el adoptado por el "programa" del Curso de nuestra Facultad desde 1948, conforme al cual se estudian después de los principios básicos y el sujeto del derecho, el acto jurídico o sea la relación jurídica en general, luego el procedimiento o sea los medios de garantizar esas relaciones, y por último cada una de las instituciones, o sea cada relación jurídica en particular.

Trata su primera parte de la teoría general del derecho romano, del sujeto del derecho, del negocio jurídico y del procedimiento. Luego, en una segunda parte, de las cosas, del dominio y de los demás derechos reales y de la posesión. En otra, de la teoría general de las obligaciones y sus fuentes. Luego de la familia y el matrimonio. Por último, de las sucesiones y de las donaciones.

Expone los principios conforme a las conclusiones más recientes, en forma clara y precisa, sin recargo de enunciación de teorías no seguidas, anticuadas o dudosas, que perturban al estudiante sin beneficiar sus conocimientos. En cambio, cuando el criterio del autor no concuerda con la doctrina dominante, cuando en el campo romanista hay una duda real o cuando un principio novedoso es digno de señalarse, estimula la curiosidad intelectual del lector, haciéndole nacer el deseo de la ampliación de sus conocimientos, por medio de observaciones agudas en el texto, de notas con referencias llenas de interés y de noticias bibliográficas seleccionadas en forma sintética pero explicativa.

No tiene recargo de citas de fuentes; lejos de ello, sólo menciona el pasaje hábilmente seleccionado por su precisión, sin tras-

cripciones que fatigan al alumno; y cuando la naturaleza del asunto lo exige, éstas son lo más breves y concisas.

De esta manera el autor ha conseguido obtener una obra ágil, de lectura agradable para el estudiante, que encierra una riqueza doctrinal enorme, expuesta en forma sintética y precisa y a la vez clara, pletórica de sugerencias, erudita y elemental a la vez, que sin fatiga alguna para el que estudia en ella, le da a conocer todo el panorama del derecho romano, con sus problemas, el resultado de las últimas investigaciones y sus referencias al derecho actual.

Es de notar cómo destaca las instituciones en el momento de su elaboración en la época clásica, dándonos la verdadera figura de ellas, para luego hacernos ver cómo se trasforman en los tiempos posclásicos y justinianeos. Las vemos así vivir entre nosotros, con su vida propia, modelándose en su ambiente, respondiendo a las necesidades del momento.

Así nos muestra cómo se forma el concepto de persona y cómo este término sólo aparece en la época de Justiniano empleado por Teófilo; lo laborioso de la formación de la doctrina de la corporación y más tarde la de la fundación, señalándonos con exactitud los elementos clásicos y los que provienen de los compiladores.

El procedimiento está tratado rigurosamente, conforme a las fuentes, sin realizar con éstas construcciones dogmáticas a base de conceptos modernos, enseñándonos cómo el proceso formulario *in iure* era esencialmente un arbitraje y la *litis contestatio* un contrato.

La propiedad y la posesión son consideradas en forma precisa, tanto en su concepto como en su evolución, con observaciones interesantes y dándonos en las notas referencias de las cuestiones planteadas en la doctrina, pero sin dejarse arrastrar por hipótesis novedosas, ni forzar interpretaciones de los textos clásicos para justificar teorías actuales.

El estudio de las fuentes de las obligaciones está realizado con sumo acierto, enfocando debidamente el espinoso asunto de la voluntad en el contrato en la época clásica, conduciéndonos por camino seguro a través de las interpolaciones, para llevarnos a las soluciones que nos parecen las más conformes con los textos, como lo señaláramos en la cátedra.

De acuerdo con la idea de MANENTI, seguida hoy por BONFANTE y la doctrina moderna, para ARANGIO-RUIZ el matrimonio clásico *sine manu* no es más que un hecho continuado que depende de la *affectio maritalis*, realizando una comparación muy feliz entre el matrimonio *cum manu* y la propiedad, y el *sine manu* y la posesión, que nos da la clara visión de aquella institución romana, diferente de nuestro concepto moderno basado en el matrimonio canónico; por ello podemos decir que el matrimonio romano era un hecho social con consecuencias jurídicas, mientras que el moderno es un acto jurídico con consecuencias sociales.

En materia de derecho sucesorio sigue las enseñanzas del gran maestro BONFANTE, explicando en breves páginas los conceptos precisos del sistema hereditario romano en el período clásico y la idea de sucesión en el derecho bizantino.

Nos encontramos, pues, con un manual de *Instituciones* que nos muestra el derecho romano tal como era en la época clásica y cómo evoluciona hasta tomar la forma que nos presenta la codificación justiniana.

No se trata de una exposición dogmática de principios, realizada con elementos romanos pero con ideología moderna, sino de una obra que nos revela aquel derecho, de la manera como surge de las fuentes depuradas, con sus conceptos genuinos, desenvolviéndose conforme a las necesidades de su momento histórico.

Ésta es la manera de encarar el estudio del derecho romano, para que él nos preste toda su utilidad en esta época de transformación jurídica. Conocer la raíz de nuestras instituciones en su verdadera manera de ser y no trasfigurada, para poder obtener el concepto íntimo de ellas, sin lo cual no se puede realizar ninguna construcción jurídica duradera. Aunque con carácter elemental, es imprescindible que el estudiante siga el mismo método para poderse compenetrar de las bases en que descansa el derecho que estudiará en su carrera.

Por eso entendemos que este curso de *Instituciones* está llamado a prestar gran utilidad a los alumnos de nuestras universidades y a los estudiosos de la ciencia jurídica que quieran tener un panorama del derecho romano u obtener sintéticamente un concepto preciso de una institución del mismo, conforme a las últimas investigaciones y a la crítica moderna.

Esperamos que esta traducción tenga la misma acogida que su original ha tenido en Italia, y con ello coadyuve al conocimiento del derecho romano, tan necesario en estos momentos.

EDUARDO R. ELGUERA

Profesor de Derecho Romano
de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires

FRANJA
MORADA

FRANJA MORADA

*A mi padre,
en la muerte como en vida*

FRANJA
MORADA

FRANJA MORADA

ÍNDICE

PRÓLOGO DEL DR. EDUARDO R. ELGUERA	IX
--	----

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN	1
El derecho romano y las diversas fases de su desarrollo: 1.	
El estudio de las Instituciones y sus precedentes clásicos y justinianeos: 10.	

PARTE GENERAL

CAPÍTULO I

EL DERECHO Y SUS DIVISIONES

§ 1. PRINCIPIOS TEÓRICOS FUNDAMENTALES	17
Concepto del derecho: a) en sentido objetivo: 17; b) en sentido subjetivo: 19. Deber jurídico: 21. Relación jurídica: 22. Los hechos jurídicos y sus tipos dominantes: 22. El negocio jurídico: 23.	
§ 2. CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍA DE LOS ROMANOS	24
<i>Ius, iuris praecepta</i> : 24. <i>Ius y fas</i> : 25. La terminología del negocio jurídico: 26.	
§ 3. LAS DIVERSAS CLASIFICACIONES ROMANAS DEL DERECHO OBJETIVO	26
Clasificaciones de carácter histórico: a) <i>ius y lex</i> : 26; b) <i>ius civile y ius honorarium</i> : 26; c) <i>ius ex scripto y ex non</i>	

<i>scripto</i> : 27; d) <i>ius civile, ius gentium, ius naturale</i> (la <i>aequitas</i>): 28. Clasificaciones sistemáticas: e) <i>ius publicum</i> y <i>ius privatum</i> : 32; f) <i>ius commune</i> y <i>ius singulare</i> : 35; <i>beneficia</i> y <i>privilegia</i> : 36.	
§ 4. CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS. ADQUISICIÓN DE LOS DERECHOS Y SUCESIÓN	37
§ 5. LA INTERPRETACIÓN DEL DERECHO	42
Concepto romano de <i>interpretatio</i> : 42; la posición de la antigua jurisprudencia frente a la ley y a la costumbre: 43. Máximas interpretativas: 44. Las limitaciones impuestas por Justiniano a la actividad de los intérpretes y las adaptaciones prácticas de las escuelas bizantinas: 45. Los romanistas y la interpretación de las fuentes jurídicas romanas: la investigación del puro derecho justiniano; la investigación histórica a través del <i>Corpus iuris</i> ; la <i>duplex interpretatio</i> . Interpretaciones e interpolaciones: 46.	

CAPÍTULO II

LOS SUJETOS DEL DERECHO (PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS)

§ 1. CONCEPTOS GENERALES Y TERMINOLOGÍA	49
§ 2. COMIENZO Y EXTINCIÓN DE LA PERSONA FÍSICA	52
§ 3. EL "STATUS LIBERTATIS": LIBRES Y ESCLAVOS	55
§ 4. EL "STATUS CIVITATIS"	59
§ 5. EL "STATUS FAMILIAE"	65
§ 6. CAUSAS DE DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA	66
1) <i>Infamés</i> : 67; 2) <i>addicti</i> y <i>nexi</i> : 68; 3) <i>auctorati</i> : 69; 4) <i>redempti ab hostibus</i> : 69. 5) La religión como causa de disminución de la capacidad: tolerancia pagana e intolerancia cristiana: 69. 6) Clases, estados, profesiones: 71; en particular, transmisión hereditaria de los oficios y colonato en el derecho posclásico: 71. 7) Limitaciones en razón del sexo: 74. Capacidad de obrar: 74.	
§ 7. LAS PERSONAS JURÍDICAS	75

CAPÍTULO III

EL NEGOCIO JURÍDICO

§ 1. DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES FUNDAMENTALES. LAS FORMAS DE LAS MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD	87
--	----

§ 2. LOS ELEMENTOS DEL NEGOCIO JURÍDICO. CONDICIÓN, TÉRMINO, MODO	93
§ 3. LA REPRESENTACIÓN EN LOS NEGOCIOS JURÍDICOS	105
§ 4. VOLUNTAD Y MANIFESTACIÓN. LOS VICIOS DE LA VOLUNTAD: ERROR, DOLO, VIOLENCIA	109

CAPÍTULO IV

DEFENSA DE LOS DERECHOS: EL PROCESO PRIVADO

Premisas	121
§ 1. LAS "LEGIS ACTIONES"	124
La <i>actio</i> como declaración de parte: ¿ <i>legis actiones</i> o simplemente <i>actiones</i> ?: 124. La originaria defensa privada y la intervención del magistrado: 125. Acciones ejecutivas y acciones declarativas: 126; el proceso <i>in iure</i> y <i>apud iudicem</i> : 126. La <i>litis contestatio</i> y sus efectos: 126. Las dos acciones primitivas: <i>manus iniectio</i> : 127; y <i>sacramentum</i> (<i>in rem</i> e <i>in personam</i>): 129. Acciones posteriores o excepcionales: <i>iudicis postulatio</i> : 133; <i>condictio</i> : 134; <i>pignoris capio</i> : 135.	
§ 2. EL PROCESO FORMULARIO	136
Los elementos caducos en el sistema de las <i>legis actiones</i> y el origen del proceso formulario: 136; la <i>lex Aebutia</i> y la <i>lex Iulia iudiciorum privatorum</i> : 138. Reducción de las acciones a términos formularios: 139. Las <i>partes formularum</i> : <i>intentio</i> , <i>demonstratio</i> , <i>condemnatio</i> , <i>adiudicatio</i> : 143. La fórmula como medio para la evolución del derecho procesal y material: fórmulas ficticias, con trasposición de condena, <i>in factum conceptae</i> : 144. Creación de la <i>exceptio</i> y su función: 147; <i>replicatio</i> , <i>duplicatio</i> , etc.: 150. Las <i>praescriptiones pro actore</i> y <i>pro reo</i> : 151. El proceso <i>in iure</i> y la <i>litis contestatio</i> : 151. El proceso <i>apud iudicem</i> : 155. Medios procesales complementarios: <i>interdicta</i> : 158; <i>in integrum restitutiones</i> : 160; <i>stipulationes praetoriae</i> : 161; <i>missiones in possessionem</i> : 161; <i>bonorum possessiones</i> : 164.	
§ 3. LA "COGNITIO EXTRA ORDINEM" Y EL PROCESO POSCLÁSICO	165
La <i>cognitio extra ordinem</i> en el proceso romano y en el de las provincias: 165; decadencia del <i>iudex privatus</i> y de las fórmulas: 167. Los distintos tipos de introducción de la <i>litis</i> en la época posclásica: 168; la <i>litis denuntiatio</i> : 169; el <i>libellus conventionis</i> : 170; y la transformación de la <i>litis contestatio</i> : 170. Principios fundamentales del proceso justiniano: ordenamiento judicial: 171; introducción y desarrollo del juicio: 172; sistema de las pruebas: 172; procedimiento de segunda instancia: 173; ejecución: 173. Procedimiento contumacial: 174. Procedimientos especiales: proceso <i>per rescriptum</i> : 175; <i>summatim cognoscere</i> : 176; <i>episcopalis audientia</i> : 176.	
§ 4. LA COSA JUZGADA Y EL CONCURSO DE LAS ACCIONES	176

LA PROPIEDAD Y LOS OTROS DERECHOS SOBRE LAS COSAS

CAPÍTULO V

LAS COSAS

Las cosas	181
Concepto de cosa: 181; cosas corporales e incorpóreas: 181. Las distinciones entre las cosas según sus características físicas y económicas: 182; y según su regulación jurídica: 187.	

CAPÍTULO VI

LOS DERECHOS REALES: DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

Los derechos reales: definición y clasificación	193
---	-----

CAPÍTULO VII

LA PROPIEDAD

§ 1. DEFINICIÓN. LOS DIVERSOS TIPOS DE PROPIEDAD EN EL DERECHO ROMANO	199
§ 2. ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA PROPIEDAD	209
Distinciones fundamentales: 209. Modos de adquisición a título originario: 1) ocupación y adquisición del tesoro: 210; 2) accesión: 212; 3) incrementos fluviales: 214; 4) especificación: 215; 5) confusión y mezcla: 216; 6) adjudicación: 217; 7) <i>litis aestimatio</i> : 217; 8) adquisición de los frutos: 218. Modos de adquisición a título derivado (transmisión): principios generales: 218. Los modos particulares: 9) <i>in iure cessio</i> : 220; 10) <i>mancipatio</i> : 221; 11) <i>traditio</i> : 225. Modos de adquisición intermedios entre los a título originario y a título derivado: 12) <i>usucapio</i> y <i>praescriptio longi temporis</i> : 230. Pérdida de la propiedad: 238.	

§ 3.	DEFENSA DE LA PROPIEDAD	239
	Los diferentes modos de ataque y de defensa: 239. Las acciones petitorias: <i>rei vindicatio</i> : 240; y medios análogos: 243; la <i>actio finium regundorum</i> : 245. Medios jurídicos de defensa contra las invasiones ajenas en la esfera de acción del propietario: <i>actio negatoria</i> : 245; <i>a. aquae pluviae arcendae</i> : 245; <i>cautio damni infecti</i> : 246; <i>operis novi nunciatio</i> : 247; <i>interdictum quod vi aut clam</i> : 247. Medios dirigidos a garantizar la expansión de la propiedad <i>in alieno</i> : <i>int. de arboribus caedendis</i> : 248; y de <i>glande legenda</i> : 249.	
§ 4.	EL CONDOMINIO	249

CAPÍTULO VIII

SERVIDUMBRES Y USUFRUCTO

§ 1.	LA TERMINOLOGÍA JUSTINIANEA DE LAS "SERVITUDES" Y LA DISTINCIÓN ENTRE SERVIDUMBRES PEDIALES Y PERSONALES	259
§ 2.	LAS SERVIDUMBRES PEDIALES	260
	Definición y principios comunes: 260; tipos y paradigmas fundamentales: 263.	
§ 3.	EL USUFRUCTO Y LOS DERECHOS ANÁLOGOS	265
	Principios fundamentales del usufructo: 265. Cuasi usufructo: 267; uso: 269; <i>fructus sine usu</i> : 270. La <i>habitatio</i> y las <i>operae servorum</i> : 270.	
§ 4.	MODOS DE ADQUISICIÓN Y DE EXTINCIÓN, DEFENSA JUDICIAL DEL USUFRUCTO Y DE LAS SERVIDUMBRES	271

CAPÍTULO IX

ENFITEUSIS Y SUPERFICIE

Enfiteusis y superficie	281
-------------------------------	-----

CAPÍTULO X

DERECHOS REALES DE GARANTÍA: PRENDA E HIPOTECA

Derechos reales de garantía: prenda e hipoteca	291
--	-----

CAPÍTULO XI

LA POSESIÓN Y LA CUASI POSESIÓN

§ 1. EL FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN DE LA POSESIÓN	299
§ 2. LA POSESIÓN Y SU PROTECCIÓN EN DERECHO ROMANO	301
§ 3. ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA POSESIÓN	308
§ 4. LA CUASI POSESIÓN DE LAS COSAS Y LA POSESIÓN DE LOS DERECHOS	310

LAS OBLIGACIONES

CAPÍTULO XII

CONCEPTO Y DESARROLLO HISTÓRICO
DE LA "OBLIGATIO"

Concepto y desarrollo histórico de la obligatio	315
---	-----

CAPÍTULO XIII

LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES

Las fuentes de las obligaciones	325
Las clasificaciones de las fuentes en la jurisprudencia clásica en general: 325; en las obras gayanas y pseudogayanas: 326; y en la compilación justiniana: 328.	

CAPÍTULO XIV

LAS OBLIGACIONES NACIDAS DE CONTRATO

§ 1. EL CONTRATO Y LA ACCIÓN CONTRACTUAL	331
§ 2. LOS CONTRATOS REALES Y LOS CONTRATOS INNOMINADOS	337

Diversa extensión de la categoría en el derecho clásico, en el justiniano y en la especulación científica posterior: 337. Los contratos reales nominados en particular: 1) mutuo: 339; 2) fiducia: 343; 3) depósito: 345; 4) comodato: 350; 5) prenda: 351. 6) Los contratos innominados: 352.	
3. LOS CONTRATOS FORMALES Y SUS SUSTITUTIVOS PRETORIOS	357
Razones que inducen a reunirlos en un solo grupo: 357. Ex-	
clusión del <i>nexum</i> : 357. Los contratos formales en particular:	
1) la <i>dotis dictio</i> : 358; 2) el <i>iusiurandum liberti</i> : 358; 3) la	
<i>vadiatura</i> : 359; 4) la <i>praediatura</i> : 360; 5) la estipulación: 361;	
6) el contrato literal clásico: 365 (los singrafas y los quiró-	
grafas del derecho helenístico y la degeneración de la esti-	
pulación en el derecho justiniano: 366); 7) el <i>iudicium</i> : 371.	
Promesas abstractas del derecho pretorio: 8) la <i>pecunia cons-</i>	
<i>tituta</i> : 372; 9) los <i>recepta</i> : 373.	
§ 4. LOS CONTRATOS CONSENSUALES	374
Concepto general: 374. Los tipos particulares: 1) compraventa:	
375; 2) locación-conducción: 384; 3) sociedad: 389; 4) man-	
dato: 391.	
§ 5. LOS PACTOS	393

CAPÍTULO XV

LAS OBLIGACIONES NO CONTRACTUALES DE ACTO LÍCITO

Las obligaciones no contractuales de acto lícito	397
1) Legados <i>per damnationem</i> y <i>sinendi modo</i> : 397. 2) Polli-	
citatio y <i>votum</i> : 398. 3) La <i>negotiorum gestio</i> y las figuras afi-	
nes: 399. 4) Tutela: 402. 5) La <i>indebiti solutio</i> y las otras hi-	
pótesis de <i>condictio</i> como acción de enriquecimiento: 402. 6)	
<i>Communio incidens</i> : 403.	

CAPÍTULO XVI

LAS OBLIGACIONES NACIDAS DE ACTO ILÍCITO

§ 1. EL DELITO Y LA ACCIÓN QUE NACE DEL DELITO	405
§ 2. LOS CUATRO DELITOS PRIVADOS DEL "IUS CIVILE"	411
1) <i>Furtum</i> : 411. 2) <i>Bona vi rapta</i> : 414. 3) <i>Iniuria</i> : 415. 4) <i>Dam-</i>	
<i>num iniuria datum</i> : 417.	
§ 3. LOS ACTOS ILÍCITOS DEL DERECHO PRETORIO (CUASI DELITOS)	420

CAPÍTULO XVII

LAS MODALIDADES Y LOS LÍMITES
DE LO ILÍCITO CIVIL

Las modalidades y los límites de lo ilícito civil	423
Ilícito contractual y extracontractual. Remisión al capítulo precedente para la responsabilidad por delito: semejanzas y diferencias: 423. La responsabilidad objetiva en las obligaciones de dar: 425. <i>Dolus, custodia, culpa</i> : 426; el origen tardío de ésta: 427; y sus grados: 428. <i>Casus fortuitus</i> y <i>periculum</i> : 430. Pactos de aumento y de disminución de la responsabilidad: 431. La mora del deudor y sus efectos: 431. La llamada mora del acreedor: 432. Los efectos de lo ilícito civil: valuación de la cosa debida y resarcimiento del daño: 433.	

CAPÍTULO XVIII

EXTINCIÓN, TRANSMISIÓN, GARANTÍAS
DE LAS OBLIGACIONES

§ 1. LOS MODOS DE EXTINCIÓN	437
Extinción <i>ipso iure</i> y <i>ope exceptionis</i> : 438. El desarrollo del concepto de <i>solutio</i> : 439; y las instituciones del derecho clásico y justiniano: 1) el pago: 439; 2) la <i>solutio per aes et libram</i> : 440; 3) la <i>acceptilatio</i> verbal y literal: 441; 4) el <i>contrarius consensus</i> : 442. Otros modos de extinción <i>ipso iure</i> : 5) novación: 442; 6) <i>concursus causarum</i> : 444; 7) confusión: 445. Modos eventuales de extinción de las obligaciones: 8) muerte y <i>capitis deminutio</i> : 445. Los modos de extinción <i>ope exceptionis</i> : 9) la compensación y su casuística en el derecho clásico y justiniano: 445; 10) el <i>pactum de non petendo</i> y la transacción: 447; 11) la <i>praescriptio longi temporis</i> : 447.	
§ 2. TRANSMISIÓN DE LOS CRÉDITOS Y DE LAS DEUDAS	448
§ 3. GARANTÍAS DE LAS OBLIGACIONES (EN ESPECIAL, LAS GARANTÍAS PERSONALES)	450

CAPÍTULO XIX

DE ALGUNOS TIPOS ESPECIALES DE OBLIGACIONES

§ 1. LAS OBLIGACIONES NATURALES	457
§ 2. LAS OBLIGACIONES GENÉRICAS Y LAS ALTERNATIVAS	462

§ 3.	DIVISIBILIDAD E INDIVISIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES	466
§ 4.	OBLIGACIONES CON PLURALIDAD DE SUJETOS (CORREALIDAD Y SOLIDARIDAD)	469

RELACIONES JURÍDICAS DE FAMILIA

CAPÍTULO XX

FAMILIA Y PARENTESCO

Familia y parentesco	477
----------------------------	-----

CAPÍTULO XXI

EL MATRIMONIO

§ 1.	EL MATRIMONIO COMO RELACIÓN PERSONAL	487
	El matrimonio <i>cum manu</i> y sus formas: <i>confarreatio</i> y <i>coemptio</i> : 487; función del <i>usus</i> en el traspaso al nuevo matrimonio <i>sine manu</i> : 488. Estructura jurídica del matrimonio clásico: 489; y justiniano: 492. Los requisitos para la validez del matrimonio: <i>connubium</i> : 492; y consentimiento: 496. Limitaciones a la libertad matrimonial en las leyes augusteas de <i>maritandis ordinibus</i> : 497; y hostilidad del Imperio cristiano hacia las segundas nupcias: 499. Efectos del matrimonio: 500.	
§ 2.	LOS ESPONSALES Y LAS "ARRHAE SPONSALICIAE"	501
§ 3.	DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO. EL DIVORCIO	503
§ 4.	RELACIONES PATRIMONIALES ENTRE CÓNYUGES. LA DOTE Y LA DONACIÓN "PROPTER NUPTIAS"	508
	La <i>conventio in manum</i> y la sucesión universal: 508. Orígenes de la dote y su empleo también en el matrimonio <i>sine manu</i> : 511. La propiedad del marido sobre la dote: 509; y los límites al derecho de disponer de ella: 512. La restitución de la dote: <i>actio ex stipulatu</i> y <i>actio rei uxoriae</i> : 512. Los <i>παράφρενα</i> : 515. La institución oriental de la <i>donatio propter nuptias</i> : 516; y su recepción en el derecho romano posclásico: 517. La práctica de la comunión de los bienes en los documentos egipcios de la época justiniana: 518.	
§ 5.	CONCUBINATO Y CONTUBERNIO	519

CAPÍTULO XXII

LA "PATRIA POTESTAS"

§ 1.	CÓMO SE ADQUIERE LA POTESTAD	523
	Procreación de hijos <i>ex iustis nuptiis</i> y <i>causae probationes</i> : 523. Adopción de extraños en la familia: la <i>adrogatio</i> y la <i>adoptio</i> , sus formas y requisitos en el derecho clásico: 524; y en el justinianeo: 527; <i>adoptio plena</i> y <i>minus plena</i> : 528. La legitimación: 529.	
§ 2.	CÓMO CESA LA POTESTAD	530
§ 3.	CONTENIDO Y DEFENSA DE LA "PATRIA POTESTAS"	533
	La potestad clásica y la justinianeas: 533. Aplicaciones a las relaciones personales: 533; y a las patrimoniales: 535. Los <i>peculia</i> : 535; y los <i>bona adventicia</i> : 537. Capacidad del <i>filius familias</i> para obligarse y para ser parte en juicio: 538. Medios judiciales para tutela de la <i>potestas</i> : 538.	

CAPÍTULO XXIII

LA POTESTAD SOBRE LOS ESCLAVOS Y LAS PERSONAS
"IN CAUSA MANCIPII"

§ 1.	LA POSICIÓN DEL ESCLAVO Y EL PROCESO DE LIBERTAD	541
§ 2.	CAUSAS DE LA ESCLAVITUD	543
§ 3.	CESACIÓN DE LA ESCLAVITUD: LA MANUMICIÓN Y EL PATRONATO ..	545
§ 4.	LAS PERSONAS "IN CAUSA MANCIPII"	551

CAPÍTULO XXIV

LAS PERSONAS "SUI IURIS" Y LA CAPACIDAD DE OBRAR:
TUTELA Y CURATELA

Premisas	555
§ 1. LA TUTELA DE LOS IMPÚBERES	557
§ 2. LA TUTELA DE LAS MUJERES	565
§ 3. LOS CURADORES	567

SUCESIONES Y DONACIONES

CAPÍTULO XXV

LA HERENCIA

- § 1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y PROBLEMAS DE ORIGEN. "HEREDITAS" Y "BONORUM POSSESSIO" 573
- Significado de *hereditas*: 573. Características de la herencia en el *ius civile* romano: predominio de la vocación testamentaria: 574; incompatibilidad entre las dos vocaciones: 574; ordenamiento particular de la sucesión de los *sui*: 575; elementos extrapatrimoniales: 575; responsabilidad *ultra vires*: 576. Dificultad de fijar la época en la cual cada principio se ha afirmado: 576. Influencia de la costumbre de la época avanzada sobre el predominio de la vocación testamentaria: 577. Reserva originaria del título de *heres* sólo a los *sui* (naturales y adoptivos): 578. La lenta agregación de los elementos extrapatrimoniales a los patrimoniales y la extensión del título de *heres*: 579. Comparación entre el desarrollo jurídico griego y el romano: 580; y desarrollo general de éste: 581. La *bonorum possessio* y su origen en las exigencias del procedimiento formulario: 584. Progresiva atribución de la posesión de los bienes fuera de toda necesidad procesal: 584. *Bonorum possessio sine re* y *cum re*: 585; *bonorum possessio secundum tabulas, sine tabulis, contra tabulas*: 587.
- § 2. EL TESTAMENTO 587
- Formas de los testamentos: 587. La *heredis institutio*: 593; herederos *pro parte, sine parte, ex re certa*: 594; *ius adcreascendi*: 596. Las sustituciones: vulgar, pupilar, ejemplar: 597. Capacidad para testar y para ser instituido: 599. Revocación y apertura de los testamentos: 602.
- § 3. LA SUCESIÓN INTESADA 605
- Sui* y *legitimi*: la herencia civil de los ingenuos: 605; y de los libertinos: 607. El sistema de la *bonorum possessio sine tabulis*: 609; y los senadoconsultos Tertuliano y Orficiano: 610. Reformas posclásicas y sistema sucesorio justinianeo: 612.
- § 4. LA SUCESIÓN CONTRA EL TESTAMENTO 614
- Sucesión necesaria formal y material: 614. La prohibición de preterición y la desheredación: 615. La *bonorum possessio contra tabulas* en la sucesión de los *liberi* y en la del patrono: 617. La *querela inofficiosi testamenti*: 617. Los legitimarios del derecho justinianeo: 619.

§ 5. LA ADQUISICIÓN DE LA HERENCIA Y LA POSICIÓN JURÍDICA DEL HEREDERO	621
La adquisición inmediata del <i>heres suus</i> y del <i>necessarius</i> y la delación al heredero extraño: 621. La intrasmisibilidad clásica de la delación y las excepciones posclásicas: 622. <i>Ius abstinendi</i> y <i>beneficium separationis</i> : 623. Los modos de aceptación de la herencia (<i>cretio</i> - <i>pro herede gestio</i> - <i>aditio</i> ?): 624; y la <i>agnitio bonorum possessionis</i> : 626. <i>Spatium deliberandi</i> : 627. Consecuencias de la relación entre delación y adquisición: <i>usucapio pro herede</i> : 627; <i>in iure cessio hereditatis</i> : 629; herencia yacente: 629. Confusión del patrimonio del difunto con el del heredero: 630; y modos de evitarla: <i>separatio bonorum</i> : 631; y <i>beneficium inventarii</i> : 631. Las acciones del heredero y contra el heredero: 632; en particular, la acción de reivindicación de la herencia (<i>petitio hereditatis</i>): 632; y la acción de división (<i>actio familiae erciscundae</i>): 635.	

CAPÍTULO XXVI

LEGADOS Y FIDEICOMISOS. LOS CODICILOS

Legados y fideicomisos. Los codicilos	637
Concepto económico del legado: 637. Los cuatro tipos jurídicos del legado romano: <i>per vindicationem</i> : 639; <i>per damnationem</i> : 639; <i>sinendi modo</i> : 640; <i>per praeceptionem</i> : 640. El senadoconsulto Neroniano: 641; y el legado del derecho Justiniano: 642. Las cargas del legado: 642. El derecho de acrecentamiento: 642. Adquisición: 644; nulidad: 644; revocación: 645. Limitaciones de los legados: 645. Estructura y origen de los fideicomisos: 647. Los fideicomisos particulares y su progresiva fusión con los legados: 648. El fideicomiso universal: 649; y de familia: 650. Los codicilos: 650.	

CAPÍTULO XXVII

LA DONACIÓN Y LA "MORTIS CAUSA DONATIO"

La donación y la <i>mortis causa donatio</i>	653
ÍNDICE ALFABÉTICO DE MATERIAS	661

INTRODUCCIÓN

EL DERECHO ROMANO Y LAS DIVERSAS FASES DE SU DESARROLLO. EL ESTUDIO DE LAS INSTITUCIONES Y SUS PRECEDENTES CLÁSICOS Y JUSTINIANEOS

La expresión *derecho romano* se refiere, como es natural, al ordenamiento jurídico vigente en las diversas épocas de la historia de Roma (monárquica, republicana, imperial). Pero los límites de tiempo dentro de los cuales se suele circunscribir la historia del derecho romano no corresponden exactamente a los de la historia romana tal como se la entiende en nuestras escuelas: coincide el punto de partida, que se halla en los orígenes de Roma (salvo las enormes dificultades que presenta, también en el campo jurídico, la reconstrucción de la más antigua historia); pero, mientras el desarrollo de la historia romana se suele considerar concluido con la caída del Imperio de Occidente (es decir, con la fecha un poco convencional del 476 d. C.), la historia del derecho romano tiene su punto de destino en la compilación de JUSTINIANO, emperador de Oriente, publicada entre los años 529 y 534 d. C. y en la sucesiva legislación del mismo emperador (†565), que desde el siglo XVI hasta el presente se agrupa bajo la denominación global de *Corpus iuris civilis*. En efecto, mientras dicha compilación, aun con todos sus defectos y falsificaciones, representa nuestra mejor y más rica fuente de informaciones, incluso para el derecho de las épocas anteriores a JUSTINIANO, la fortuna que tuvo en la época medieval y moderna, y aun más en Occidente que en Oriente, hace que los modernos derechos europeos puedan considerarse en gran parte como derivaciones y adaptaciones del derecho justiniano. En cambio, el derecho posjustiniano se halla en general fuera del campo de nuestros estudios; la evolución producida en el Imperio de Oriente después de JUSTINIANO (derecho bizantino), sólo puede interesarnos en cuanto sirve para

comprender el espíritu y las tendencias del derecho justinianeo; la que se produjo en Occidente, desde que el derecho justinianeo fué enseñado en las escuelas y recibido como ley vigente, entra en el ámbito de otras disciplinas (derecho romano en la Edad media, derecho común), que pueden hallar ubicación en los programas universitarios de historia del derecho italiano.

De todos modos, es evidente que, no podemos conocer en cada una de sus partes el desarrollo cumplido a través de los doce siglos transcurridos desde la fundación de Roma hasta JUSTINIANO.

Del antiguo *ius civile*, que domina indiscutido hasta el 600, aproximadamente, de la fundación de Roma (hacia 150 a. C.), tenemos un conocimiento casi exclusivamente indirecto. Lo que en este período predomina y a lo que más estrictamente se reserva el nombre de *ius*, es la costumbre probablemente heredada, por lo menos en sus estructuras fundamentales, de los diversos pueblos (latinos, sabinos, etruscos) que constituyeron la primera población de la Ciudad, y desarrollada luego en Roma al impulso de las necesidades prácticas y según formularios preparados primero en el colegio de los pontífices —que tenía antiguamente el monopolio de la jurisprudencia—, y después por juristas laicos, que gozaban de la confianza pública. Sólo excepcionalmente interviene la *lex*, propuesta por el magistrado y votada por los comicios populares, para oponer un dique a las aplicaciones abusivas de la costumbre: tal carácter, visible en la misma denominación de las leyes particulares de que tenemos noticia (*lex Aquilia de damno*, *lex Atilia de tutore dando*, *lex Plaetoria de circumscriptione adolescentium*, y muchas otras), era en realidad propio también de la ley de las XII Tabas, no obstante que los escritores romanos de siglos posteriores, frente a los muchos y variados asuntos a que ella se refería, tuvieran la opinión —mantenida también por los modernos— de que en ella estaban codificadas todas las antiguas costumbres. *Ius* y *lex* son, para los romanos de la república, los dos términos de una antítesis; y su síntesis representa el derecho vigente¹.

¹ Sobre todo esto, cfr. ROTONDI, *Osservazioni sulla legislazione comiziale romana di diritto privato*, en la revista "Il Filangieri", t. 35, 1910, ps. 641 y ss. (= *Scritti giuridici*, I, ps. 1 y ss.); y ahora mi *Storia del dir. rom.*, 5ª ed., Napoli, 1947, ps. 64 y ss., 136 y ss. A esta obra remito para el estudio de todo cuanto está sumariamente indicado en la presente Introducción.

Pero ya a mediados del segundo siglo a. C. comienza a perfilarse un nuevo sistema jurídico que nace de la actividad de los magistrados *jusdicentes* (principalmente del *praetor urbanus*), con la tendencia cada vez más manifiesta de integrar y corregir las normas del *ius civile*. Los orígenes de este nuevo sistema jurídico, que toma el nombre de *ius praetorium* u *honorarium*, no resultan muy claros; no alcanzamos, sobre todo, a comprender plenamente la justificación constitucional que de él se dieron los romanos². Ciertamente es que el magistrado, a quien correspondía guiar a las partes y controlar sus actos en el planteamiento de las controversias que habían de someterse al juicio de los tribunales o de los árbitros, fué asumiendo, frente a las normas que desde antes regulaban rígidamente toda su actividad y la de las partes, poderes discrecionales de singular amplitud: denegar al actor una acción que por derecho civil le correspondía, pero cuya concesión aparecía en el caso concreto, por circunstancias particulares, inícia; autorizar al juez a absolver al demandado cuando, aun resultando totalmente fundada, de hecho y de derecho, la pretensión del actor, aquél opusiera algunas circunstancias de hecho, tales como un acuerdo concluído entre las partes en formas civilmente no vinculantes (*exceptiones*); imponer, previamente al juicio o extrajudicialmente, el intercambio de determinadas promesas entre las partes, de modo que la violación de la promesa diera lugar a una acción judicial con el resultado de proteger relaciones que de otra manera no habrían tenido tutela (*cautiones*); otorgar la posesión de los bienes hereditarios (*bonorum possessio*) a personas diversas de aquellas a que el derecho civil llamaba a la herencia, protegiendo a los poseedores así constituidos, con *exceptiones* y con otros medios idóneos, aun contra el verdadero heredero; conceder nuevas acciones en tutela de relaciones que el derecho civil no había contemplado (*actiones* o *formulae in factum*); etc. Todo esto no al azar ni con motivo de tal o cual controversia, sino según reglas fijas que el nuevo pretor elegido publicaba en un *album* como principios a los cuales se habría de ajustar durante el año de ejercicio del cargo: *edictum perpetuum* en este sentido, pero que llegó a ser después perpetuo en el sentido usual de la palabra,

² Sobre el tema, cfr. BETTI, en los *Studi in onore di G. Chiovenda*, Padova, 1927; y mi *Storia*, ps. 149 y ss.

cuando todas las máximas que se habían evidenciado prácticamente útiles se fueron transmitiendo de año en año, de pretor a pretor, llegando a formar un *corpus* tradicionalmente intangible. Este desarrollo se cumple totalmente en la época republicana: al principio de la época imperial la actividad innovadora del pretor no encuentra más lugar sino en cuanto es requerida de tanto en tanto por senadoconsultos o por edictos imperiales; pero, probablemente alrededor del año 126 d. C., el emperador Adriano encomendó a un jurista, SALVIO JULIANO, la misión de organizar definitivamente el Edicto pretorio, haciendo aprobar esta sistematización mediante un senadoconsulto. Derecho civil y derecho pretorio subsistieron, sin embargo, como dos sistemas bien distintos, que los juristas comentaban separadamente, sin considerarse en momento alguno que el segundo hubiera derogado al primero ni siquiera en los casos en que lo reducía prácticamente a un vano nombre; sólo JUSTINIANO bosquejó su fusión en un sistema único.

En los primeros siglos de la edad imperial (época del Principado, en que el nuevo régimen respeta, por lo menos formalmente, las tradiciones romanas de derecho público y privado), nuevos modos de formación de las normas jurídicas se vienen elaborando lentamente: después de un brillante florecimiento de los senadoconsultos, la actividad normativa del príncipe se manifiesta con los edictos, los mandatos, los rescriptos, los decretos (*constitutiones principum*). Pero un fenómeno mucho más importante es el desarrollo que adquiere en esta época la ciencia jurídica. Originariamente había existido más bien un arte que una ciencia del derecho, arte que se expresaba en las fórmulas cautas y lapidarias elaboradas para los actos de la vida jurídica por el colegio de los pontífices primero y luego por los juristas laicos. Pero ya en estos antiquísimos tiempos no debía faltar una tendencia (y de ella queda algún precioso vestigio) a la sistematización y justificación de los datos ofrecidos por la ley y la costumbre; y más tarde, cuando toda la vida romana se va impregnando de cultura filosófica, surgen también en el campo jurídico los hombres de ciencia: principalísimos entre ellos son Q. Mucio Scevola y Servio Sulpicio Rufo, contemporáneos de Cicerón. En la época que transcurre de Augusto a los Severos (31 a. C. - 235 d. C.), la ciencia del derecho encuentra cada día nuevos cultores y se constituye en disciplina enteramente autónoma, llegando con medios técnicos

insuperables a la más exquisita determinación de las categorías y de las instituciones jurídicas y a la más perfecta adecuación de la teoría con la práctica. En esta obra rica y multiforme, que constituye la mayor originalidad del pensamiento romano frente al griego, se halla la raíz de la impresionante persistencia del derecho romano como forma del pensamiento jurídico; todavía hoy no hay jurista que no sea, aun sin saberlo, romanista, porque no hay sustancia jurídica que nos sea exactamente inteligible si antes no la hemos vaciado en los moldes preparados por los juristas de Roma. El derecho de los países que no participaron de la tradición romanística (como Inglaterra) representa para nosotros un secreto difícilmente penetrable: como si —desde el punto de vista jurídico— aquellos países no hubiesen adquirido jamás conciencia de sí. Precisamente, por la altura que alcanzó la jurisprudencia, la época del Principado toma, para nosotros, los juristas, la denominación de *época clásica*.

A principios del siglo III se inicia en el derecho romano una nueva revolución, más vasta y profunda que la que hemos descrito como *ius honorarium*. El punto de partida está en la constitución de ANTONINO CARACALLA, dictada en el 212, mediante la cual se concedía la ciudadanía a todos los habitantes del Imperio. La concesión (motivada quizá por una tendencia hacia el sincrismo religioso entre Roma y el Oriente, o tal vez también por necesidades financieras) destruía la eficacia del principio de la personalidad del derecho, que hasta entonces los romanos habían aplicado respecto de las provincias; mientras que hasta el año 212 cada uno de los pueblos sometidos había seguido viviendo, en lo concerniente a relaciones familiares y patrimoniales, con sujeción a su propio derecho, desde el 212 en adelante fué el derecho romano el que se convirtió en derecho vigente para todos. Ahora bien: entre el derecho romano y el de los otros pueblos de la cuenca del Mediterráneo (impregnados todos, desde la conquista de Alejandro, de civilización griega) había diferencias de estructura tan fundamentales, que ni la más decidida voluntad de ajustarse al derecho imperial habría podido bastar para vencer la presión del derecho local: se perfiló así, a partir del siglo III, una lucha sorda entre ambas normas, y en esa lucha más y más veces las reglas romanas terminaron por sucumbir. Podemos seguir esta lucha paso a paso en los infinitos documentos de la vida jurídica

que los papiros greco-egipcios ofrecen a nuestra vista y en los rescriptos imperiales de la época, reunidos en parte en el código justiniano; hasta Diocleciano, es decir, hasta los primeros años del siglo IV, los emperadores refirman, frente a las divergentes pretensiones de las provincias, las máximas del derecho clásico; desde Constantino en adelante, el traslado al Oriente del centro del Imperio, hace que el derecho de los países helenísticos adquiera predominio en muchos detalles³.

No menos enérgica fué, aunque muchos lo pongan en duda, la influencia ejercida sobre numerosas instituciones del derecho romano por la nueva religión que triunfó con Constantino. No sólo en el sentido de que se tuvo por primera vez una Iglesia que se contrapuso al Estado como poder a poder, con la consiguiente necesidad de regular sus recíprocas relaciones, sino en el sentido de que la nueva concepción del mundo expresada en el cristianismo, vino informando todas las instituciones jurídicas, limitando y suavizando la esclavitud, obstaculizando el divorcio, introduciendo en la rigidez individualística de la propiedad romana mayor consideración por los intereses sociales y por los de los vecinos, protegiendo por doquiera y de todos modos al deudor frente al acreedor⁴.

En la medida en que se trasformaba el contenido de las normas particulares, se modificaban también las formas y los pro-

³ El problema de las relaciones entre derecho imperial y derecho local fué planteado admirablemente en la obra hoy clásica de L. MITTELS, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreiches* (Derecho del imperio y derecho popular en las provincias orientales del imperio romano), Leipzig, 1891. Las ediciones de textos papirológicos, que en los últimos decenios se han multiplicado (basta señalar las colecciones monumentales del British Museum, de Oxford [provenientes en gran parte de la antigua 'Οἰκουμενικὴ πόλις en la Tebaida], de Berlín, de Florencia, etc.), han dado lugar a toda una literatura: una cretomatía reciente, adaptada para una primera iniciación, es la de P. M. MAYER, *Juristische Papyri*, Berlín, 1920, y muchos se pueden leer en las *Leges* recopiladas por RICCOBONO y en los *Negotia* por mí preparados (*Fontes iuris Rom. antetustiniani*, resp. vols. I y III, Firenze, 1941 y 1943). Italia, que tiene dos ricas colecciones papirológicas, conservadas ambas en la Biblioteca Mediceo Laurenziana de Florencia y doctamente ilustradas en las ediciones dirigidas por JERÓNIMO VITELLI y sus alumnos, tiene también una revista especial, "Ægyptus", dirigida por CALDERINI: entre nuestros romanistas, han cultivado este campo de estudios, principalmente, SCIALOJA, DE RUGGIERO, BORTOLUCCI, DE FRANCISCI, A. SEGRÈ y el que escribe.

⁴ Sobre esto ver principalmente RICCOBONO, *Cristianesimo e diritto privato*, en la "Riv. di Dir. Civile", III, 1911, ps. 37 y ss.

cedimientos del pensamiento jurídico. La lucidez y la inmediatez del pensamiento clásico eran sustituidas por todo un juego de conceptos y subconceptos, de distinciones y subdistinciones, un fantasear en torno a hipótesis extrañas a la vida del derecho, de donde las instituciones salían tan torpemente desvirtuadas y estilizadas como la filosofía platónica a través de Plotino. En el método de los maestros de las dos escuelas jurídicas de Constantinopla y de Berito, se encuentra todo el espíritu que oscurece las disputas teológicas de los padres de la Iglesia bizantina; un estudio comparativo de la literatura teológica con la literatura jurídica está aún por hacerse, pero lo poco que sabemos sobre el particular es suficiente para darnos un indicio de la importancia de los resultados a que podría llevar.

Entre las nuevas exigencias prácticas y doctrinales y el modelo insuperable del derecho clásico, JUSTINIANO intentó una conciliación. Ilírico y cristiano, fué sin embargo en toda su actividad de guerra y de paz el más ferviente defensor de la romanidad; y así como intentó infructuosamente reconstituir el imperio de Constantino, así también intentó, en sus compilaciones jurídicas, infundir nuevamente un espíritu clásico en el derecho vigente. Su compilación fué doble: de *leges* y de *iura*, según la terminología ya introducida desde algunos siglos atrás. Compilación de *leges*, es decir, de constituciones imperiales, fué el *Codex*, que reuniendo en gran parte el material de las dos colecciones privadas que se habían hecho bajo Diocleciano (*codex Gregorianus* y *Hermogenianus*) y de la colección oficial publicada en 438 por Teodosio II y Valentiniano III (*codex Theodosianus*) e integrándolo con las constituciones posteriores, contenía el producto de la más reciente evolución. Compilación de *iura*, es decir, de textos de la jurisprudencia clásica, fueron los *Digesta* o *Pandectae* en los cuales debía revivir el pensamiento jurídico de los antiguos, con todas las adaptaciones impuestas por los cambios ocurridos en las normas particulares. En la constitución que promulga los *Digesta* (o, como hoy decimos habitualmente, el Digesto) JUSTINIANO insiste en proclamar su respeto por la antigüedad, pero nos advierte asimismo que *multa et maxima propter utilitatem rerum transformata sunt*: ello mediante supresiones, agregados, modificaciones del texto genuino, que los romanistas indican con el nombre de *interpolaciones*. Y debe tenerse presente que los libros de los antiguos no habían

llegado intactos a manos de la comisión encargada de la compilación del Digesto; había ocurrido muchas veces que estudiosos posclásicos glosaran de diversa manera los ejemplares que poseían, ya para interpretarlos, ya para actualizarlos con las más recientes innovaciones, y que las glosas se incorporaran con el texto en la tradición manuscrita (*glosemas* o *interpolaciones prejustinianas*). Análogas manipulaciones sufrieron, por lo demás, también las constituciones —y no solamente las más antiguas— introducidas en el Código.

Era natural que la audaz tentativa de JUSTINIANO llevara a una obra en extremo imperfecta; deficiente es, especialmente, esa parte de la compilación que se quería más perfecta: el Digesto. La idea de presentar un *derecho romano-helénico* en ropaje clásico debía producir necesariamente este resultado: que a veces la diversa estructura del cuerpo desnaturalizara el hábito, y otras veces el hábito ocultara por completo el cuerpo que debía vestir. Para conocer el derecho de JUSTINIANO en sus normas prácticas, y más aún en su espíritu, es menester a menudo mirar, fuera de la compilación, en los índices que de ella suministra la redacción griega conocida con el nombre de *Basílicas* (siglo IX), y sobre todo en los escolios antiguos de las mismas Basílicas, donde las tendencias del ambiente bizantino son iluminadas por los juristas contemporáneos o poco posteriores a JUSTINIANO; eliminada la necesidad de introducir casi furtivamente el nuevo pensamiento en los antiguos textos, los juristas bizantinos se manifiestan aquí en su genuina *forma mentis* que no guarda ya ningún rasgo común con la forma clásica. En cambio, para conocer el derecho clásico es necesario suprimir de los textos de las compilaciones justinianas las interpolaciones que se le han introducido; a esta obra, a la que desde hace cincuenta años se consagran las mejores fuerzas de la ciencia romanística, se provee con los más variados medios, especialmente con el examen comparativo de los textos particulares de la misma compilación, no todos igualmente bien interpolados, y en consecuencia plagados de contradicciones, y con el estudio lingüístico, que permite descubrir en los textos interpolados errores gramaticales, helenismos, vocablos y formas desconocidos a la latinidad clásica. El más valioso aporte es el que ofrecen los textos de la jurisprudencia llegados a nuestras manos fuera de la compilación justiniana; desgraciadamente, esos textos son muy escasos, y varios de ellos, más que obras clásicas genuinas, son

epítomes y crestomatías posclásicas en las cuales el texto del jurista ha sido reelaborado por manos inexpertas y se ha llenado de glosemas.

El conocimiento del derecho justiniano y el del derecho clásico son esenciales para la ciencia y la enseñanza romanística: del derecho justiniano no puede prescindirse si se quiere comprender la génesis del derecho actual de la Europa occidental; pero el conocimiento del derecho clásico sirve para satisfacer esa exigencia de disciplina propia del pensamiento jurídico, de la cual hemos dicho que no existen maestros comparables a los jurisconsultos de Roma. En el estudio dogmático del derecho romano, al que se refieren los cursos de Instituciones y de Pandectas, el derecho primitivo sólo interesa en la medida en que su conocimiento (o más a menudo las hipótesis que se intenta construir) sirve para explicar el derecho clásico; las investigaciones especiales al respecto corresponden al curso de historia del derecho romano. La limitación del campo de ambos cursos dogmáticos al derecho privado y a su respectivo proceso, tiene su razón no tanto en el hecho de que al derecho privado se le reconoce una tradición ininterrumpida que liga nuestro pensamiento jurídico y la sustancia de nuestro derecho a la antigüedad romana, como en el hecho de que ni los mismos juristas romanos hicieron objeto de hondas investigaciones ni construyeron como sistema otra materia que la del derecho y del proceso privado, único objeto que se presentaba a su espíritu cuando hablaban de *ius*⁵.

⁵ Bastaría para probarlo el sistema de las *Instituciones*: cuando GAYO (I, 8) dice que "*omne... ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad acciones*", su horizonte no va más allá del derecho privado; en efecto, en toda la obra no se habla nunca de derecho público. En las *Instituciones* justinianas, la *pars de actionibus* tiene un apéndice de *publicis iudiciis* (4, 18) relativa al proceso criminal; pero JUSTINIANO mismo veía que estos *iudicia* no tienen nada de común con las *acciones*, y con esto reconocía que su agregación no mejora sino que más bien deforma el sistema. Entre las obras científicas más vastas, los comentarios al *ius civile*, elaborados sobre el modelo de las ejemplares exposiciones de Q. MUCIO SCEVOLA y de MASURIO SABINO, abrazan, con diverso orden sistemático, casi las mismas materias privatísticas comprendidas en los *libri institutionum*, y los *libri ad edictum* se refieren directamente a las funciones del magistrado judicial en las controversias familiares y patrimoniales entre particulares.

La misma distinción entre *ius publicum* y *ius privatum*, que parecería contraria al orden de ideas aquí expuesto, es entendida frecuentemente por los romanos en un sentido muy diverso del actual: *ius publicum* no

Pero ¿cuál es el objeto específico de nuestro curso de Instituciones? Su misma denominación lo dice exactamente. *Instituere*, para los romanos, equivale a educar, a iniciar a alguno en determinada disciplina: piénsese, por ejemplo, en las *Institutiones oratoriae* de QUINTILIANO y en las *Institutiones divinae* de LACTANCIO. También para el estudio del derecho los juristas clásicos vieron la utilidad de los pequeños tratados elementales, y precisamente les dieron, con preferencia, el nombre de *institutiones* (sobrentendiéndose: *iuris*, o *iuris civilis*). Inspirándose en estos precedentes, también JUSTINIANO publicó, como agregado de las dos partes fundamentales de la compilación, un tratado elemental en cuatro libros, compilado por TRIBONIANO (el mismo *quaestor sacri palatii* que presidió las comisiones para la compilación del Digesto y para la segunda edición del Código) y por los dos profesores de derecho TEÓFILO y DOROTEO. Y en la constitución *Omnem*, que precede a las Pandectas y está destinada a regular el orden de los estudios en las escuelas de Constantinopla y de Berito, se establecía precisamente que los alumnos de primer año estudiaran las Instituciones, para penetrar, en los años sucesivos, en el estudio del Digesto. La distribución de la enseñanza italiana del derecho romano privado en los dos cursos de Instituciones y de Derecho romano (o *Pandectas*), se remonta hasta este ejemplo justiniano, y aun hasta el tiempo anterior, en el cual —como la misma constitución lo dice— en la base de la enseñanza del primer año estaban las Instituciones de GAYO, mientras que en los años sucesivos se estudiaban obras y compilaciones más profundas.

es tanto el derecho que se refiere al Estado, como el derecho que emana del Estado, en contraposición a las normas que dan los particulares a la conducta propia o ajena en los contratos y en los testamentos. Ver más adelante, p. 34. También a la distinción entre *ius civile* y *ius gentium* se la presenta siempre abarcando todo el derecho, aunque carezca de sentido fuera del derecho privado. La verdad es que la atención de los juristas se vuelve al derecho público sólo excepcionalmente, considerando casi a la soberanía y su aplicación, como un dato de hecho no susceptible de construcción y valoración jurídica: no en vano uno de los más grandes estudiosos de nuestras fuentes (PEROZZI, *Ist.*, I, n.º 80, n. 2) se ha formado de la soberanía el mismo concepto.

Todavía hoy el nombre de *ius civile*, que en la Edad media indicó el derecho romano como contrapuesto al derecho canónico, revive como sinónimo de derecho privado.

También las Instituciones de JUSTINIANO son, como las *Pandectas* y el Código, una compilación: sólo que mientras en las dos compilaciones mayores cada uno de los fragmentos de obras clásicas y cada constitución lleva la indicación de su procedencia (*inscriptio*); las Instituciones se presentan como una exposición continua, en la que el emperador resume los principios del derecho, recordando, cuando corresponde, los antecedentes históricos y señalando, toda vez que se ofrece la ocasión, sus propias reformas. Solamente un estudio cuidadoso de los diversos estilos y la confrontación con textos de distintas procedencias, permite investigar, dentro de ciertos límites, las fuentes que utilizaron los compiladores⁶.

Las fuentes principales del pequeño tratado, enumeradas en la constitución *Imperatoriam* con la que fué promulgado, fueron las obras de los clásicos designadas con el mismo nombre de *Institutiones*, sobre todo las Instituciones de GAYO.

Tenemos la fortuna de poseer el texto original de esta última obra. En 1816, el historiador NIEBUHR, que examinaba en la biblioteca capitular de Verona un manuscrito de San Jerónimo, advirtió que el pergamino había sido ya usado precedentemente y raspado para trascribir la obra jeronimiana (esto es, se trataba de un palimpsesto); y en algunos rastros de la escritura anterior reconoció una obra de la jurisprudencia romana. Con el auxilio de reactivos adecuados para hacer revivir la primitiva escritura, pudieron reconocerse las Instituciones de GAYO lográndose recuperar el texto en su casi totalidad: salvo algunas partes irremediablemente perdidas y otras en que el abuso de los reactivos destruyó la escritura haciendo ilegibles largos fragmentos del precioso manuscrito⁷.

⁶ La mejor tentativa en este sentido es la de FERRINI, *Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano*, en "Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano", XIII (1900), ps. 101 y ss. (= *Opere*, II, ps. 307 y ss.); pero véase, respecto al aprovechamiento de las dos obras de GAYO, ARANGIO RUIZ, *Sul liber singularis regularum: appunti gaiani*, en el mismo "Bullettino", XXX (1921), ps. 178 y ss.

⁷ Entre las mejores ediciones recordamos la de KRUEGER y de STRUMUND, en la *Collectio librorum iuris anteiustiniani* de Berlín, vol. I, y la de SECKEL y de KUEBLER en las *Fontes iuris romani anteiustiniani* de Leipzig (Teubner), vol. I.

Alguna página de las *Institutiones*, perteneciente a otro manuscrito, fué encontrada en Egipto en 1833 y publicada por mí en P. S. I. (*Papiri*

Con el descubrimiento de NIEBUHR se inició una nueva era en los estudios de derecho romano. Es, en efecto, ésta de GAYO, la única obra de la jurisprudencia clásica que nos ha llegado en su forma originaria; que aquí y allí se haya deslizado alguno de los glosemas de que ninguna obra de la antigüedad puede considerarse inmune, es probable; pero que esos glosemas sean muchos y que en el manuscrito veronés deban reconocerse reelaboraciones destinadas a poner la obra al corriente con la evolución científica y jurídica posclásica, es una afirmación arbitraria, aun cuando la hayan aceptado algunos romanistas. Y por eso el escrito de GAYO representa el más valioso término de confrontación para verificar en muchos puntos lo genuino de los principios atribuidos en la compilación justiniana a la antigua jurisprudencia; más aún: en algunas materias ese escrito es la única fuente para el conocimiento del derecho clásico.

Por lo demás, el autor de las Instituciones es la figura más enigmática que presenta la jurisprudencia romana. Las Instituciones que el manuscrito veronés nos ha conservado fueron escritas alrededor del 161 d. C., poco antes y poco después de la muerte de Antonino Pío, que en el libro I y a principios del II es llamado *imperator*, mientras que al finalizar este mismo libro II recibe el nombre de *divus*, propio de todo emperador difunto. El mismo jurista era también autor de otras obras: un comentario a la ley de las XII Tablas, otro *ad edictum provinciale*, otro a títulos elegidos del Edicto del pretor urbano, y otras obras menores, aprovechadas también (con mucha parsimonia, por cierto) para la compilación del Digesto.

Pero de GAYO sólo conocemos el nombre de pila, que nada nos dice sobre su persona; y lo peor es que ninguno de los juristas contemporáneos ni posteriores (de los que poseemos, a través del Digesto, abundantes materiales, y que no eran avaros en las citas recíprocas) muestra haber tenido conocimiento de la existencia de GAYO. En cambio, su fama aparece notablemente difundida en la época posclásica: un *liber singularis regularum*, atribuido falsamente a ULPIANO, es en gran parte un epítome de las Ins-

della Società Ital.), XI, 1182: cfr. "Bull. Ist. Dir. Rom.", nueva serie, I, 1935, ps. 571 y ss., donde están resumidas las discusiones provocadas por el nuevo texto en su primera aparición.

tituciones gayanas; otro epítome se encuentra en la *lex Romana Visigothorum* del año 506; la ley de las citas de Teodosio II y Valentiniano III (año 426), que limitaba a cinco el número de los juristas antiguos de quienes era lícito citar las obras en los tribunales, incluía a GAYO entre los cinco; un maestro de derecho de la misma época, de cuyas poco doctas lecciones se tienen fragmentos en un manuscrito recientemente descubierto en Autun (*fragmenta interpretationis Gaii Augustodunensia*) comentaba las Instituciones con servil fidelidad al texto; simultáneamente los maestros de las escuelas orientales elaboraban una especie de paráfrasis bajo el nombre de *Res cotidianae* o de *Aurea*⁸; en fin, el orden prejustiniano de los estudios, descrito en el § 1 de la constitución *Omnes* del mismo JUSTINIANO, asignaba el primer puesto a las Instituciones de GAYO. Todo esto, y además los no pocos helenismos del estilo gayano, el comentario al Edicto provincial y la relativa frecuencia con que en las Instituciones se recuerda el derecho de los pueblos helenísticos u orientales, hace suponer que el autor de la época de los Antoninos viviese en provincia y probablemente en Oriente.

Alguien ha buscado la explicación del hecho de que el jurista sea recordado sólo con el prenombre, en la hipótesis de que hubiera adoptado ese prenombre en el momento en que se le confirió la ciudadanía romana; pero tal hipótesis no satisface plenamente, porque aun romanizados, los súbditos solían seguir llevando al lado del prenombre o nombre romano que adoptaban, su nombre originario. Más bien cabría observar que entre los juristas clásicos se usaba citar con el simple prenombre *Gaius* al viejo C. CASSIO LONGINO, que vivió en la época de Tiberio y de Calígula, y que, por otra parte, las Instituciones presentan varias señales de sucesivas redacciones: lo que podría hacer pensar que el primer texto de la obra se deba precisamente a CASSIO LONGINO, mientras que el jurista provincial de la época de los Antoninos sólo la habría actualizado y renovado en algunos puntos, aprovechando luego también para otras obras, y casi como seudónimo, el nombre de GAYO⁹.

⁸ Ver especialmente mi contribución a los *Studi in onore de P. Bonfante*, 1930, I, ps. 493 y ss.; y últimamente DI MARZO, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 51-52 (1948), ps. 157 y ss.

⁹ Cfr. para esta tesis: HUVELIN, *Études sur le furtum dans le très ancien droit romain*, Lyon, 1915, ps. 585 y ss.; y mi *Storia*, p. 283.

La división en cuatro libros a que nos hemos referido precedentemente, responde —como es general en las obras de la antigüedad— más a exigencias de volumen que a criterios sistemáticos. En efecto, después de haber sentado algunas clasificaciones fundamentales en el campo del derecho objetivo (I, 1-7), GAYO advierte (I, 8) que *omne... ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones*, con lo que distribuye sistemáticamente en tres partes toda la materia del derecho privado. Las partes primera y tercera coinciden respectivamente con los libros primero y cuarto; la segunda parte, que es la más vasta, abarca los libros segundo y tercero.

Fácil es decir cuáles son los temas tratados en las partes de *personis* y de *actionibus*. En el libro de las personas se examinan las diferentes posiciones jurídicas de los hombres, según sean libres o esclavos, ingenuos o libertinos, ciudadanos o extranjeros, *sui iuris* o *alieni iuris* (esto es, titulares de derechos propios o sujetos a potestad de otros), y según que, siendo *sui iuris*, tengan o no necesidad de asistencia en los actos jurídicos (de ahí la consideración de la tutela y de la curatela); en el libro de *actionibus* se examina el proceso civil desde el punto de vista de la acción, es decir, del medio técnico que se ofrece al particular para obtener la declaración de su derecho y para realizarlo.

La parte de *rebus* comprende, en cambio, todo el derecho patrimonial. Partiendo de un concepto amplísimo de cosa, y de la distinción entre *res corporales* e *incorporales* (II, 12 y ss.), y considerando como cosas incorporales a todos los derechos patrimoniales distintos de la propiedad (los derechos reales sobre las cosas de otros, los créditos, la titularidad de una *hereditas*), los dos libros sobre las cosas han podido abarcar sin gran esfuerzo todos los aspectos del derecho privado que no entraban en las categorías del *ius quod ad personas* y del *ius quod ad actiones pertinet*.

Sin embargo, el sistema, no superior por cierto a toda crítica, tuvo gran fortuna: no sólo fué seguido, aun en los detalles de su actuación, en las Instituciones justinianeas, sino que se reprodujo sin variaciones en las obras sistemáticas de la Edad media y de los tiempos modernos, y en los mismos códigos de las naciones latinas. Y aun más: habiéndose dejado de recurrir al concepto de cosa incorporal, se ha quitado al sistema adoptado todo principio de justificación; era absurdo, por ejemplo, que el tercer libro del Cód. Civil italiano de 1865 se titulase "De los modos de

adquirir y transmitir la propiedad y los otros derechos sobre las cosas", mientras se trataba en él, entre otras materias, de las obligaciones, las que sólo en contados casos llevan (indirectamente) a una adquisición o transmisión de propiedad o a la constitución de un derecho real. Peor aún en el recentísimo *Codex iuris canonici*, donde, queriéndose conservar la tripartición gayana, se han considerado como *res* hasta los sacramentos.

Los tratados más recientes y autorizados sobre las Instituciones de derecho romano¹⁰ se han liberado de la servil obsecuencia a la tradición; los criterios adoptados son diversos, pero coinciden en agrupar las distintas partes del sistema según la conexión y las recíprocas influencias de las normas respectivas: así la materia de los derechos reales (o sobre las cosas) se vincula con la de las obligaciones, y los derechos de familia van unidos a las sucesiones. Y estos tratados van precedidos, como *parte general*, de aquellas nociones que constituyen sus supuestos comunes.

¹⁰ Citamos entre los óptimos los manuales de BONFANTE (reimpr. 10ª ed., Torino, 1946) y de PEROZZI (2 vols., 2ª ed., Firenze, 1928). Al lado de ellos recordamos, entre los últimos tratados alemanes, RABEL, *Lineamenti del diritto privato romano* [*Grundzüge des römischen Privatrechts*], en la "Enciclopedia Giuridica" de HOLTZENDORFF y KOHLER, 7ª ed., 1915; SIBER, *Römisches Recht in Grundzügen für die Vorlesung* [*Derecho romano resumido para la enseñanza*], II, *Derecho privado*, Berlín, 1928; [JOERS-] KUNKEL, *Römisches Recht*, Berlín, 1935. Entre los franceses se señala, además del ahora clásico GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain* (8ª ed., dirigida por SENN, París, 1929; trad. LONGO, Milano, 1908), también el reciente tratado de R. MONIER (mismo título: 2 vols., 6ª ed., París, 1947-1948). Una reconstrucción metódica del derecho clásico fué iniciada por MITTEIS, *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians* [*Derecho romano privado hasta la época de Diocleciano*]; pero el único volumen que el lamentado escritor pudo publicar (Leipzig, 1908) comprende solamente las doctrinas generales y la de las personas jurídicas. Igualmente ha quedado interrumpido por la muerte del autor (1932) el *Corso di diritto romano* que BONFANTE había proyectado como un tratado completo de la materia: se han publicado los tres primeros volúmenes (familia, propiedad, derechos reales sobre la cosa de otro y posesión), y sólo la parte general del volumen VI (sucesiones).

Es inútil insistir sobre la utilidad que ofrecen al jurista, y en especial al estudioso del derecho justiniano, los clásicos tratados de los pandectistas alemanes del siglo XIX (SAVIGNY, PUCHTA, VANGEROW, WINDSCHEID, etc.).

FRANJA MORADA

PARTE GENERAL

CAPÍTULO I

EL DERECHO Y SUS DIVISIONES

§ 1. PRINCIPIOS TEÓRICOS FUNDAMENTALES

Concepto del derecho: a) en sentido objetivo; b) en sentido subjetivo.
Deber jurídico. Los hechos jurídicos y sus tipos dominantes: el negocio jurídico.

La escasa propensión de la jurisprudencia romana por la especulación conceptual, hace que una mente moderna no pueda compendiar el sistema jurídico de Roma bajo las pocas ideas generales, o más bien impresiones de conjunto, expresadas aquí y allí por los juristas antiguos. Esta circunstancia nos obliga a anteponer a nuestra exposición algunas nociones dogmáticas de origen moderno que, en su aspiración a dar razón de todo fenómeno jurídico, valen también para el derecho romano.

Ante todo debemos buscar en este complejo de nociones la respuesta a la pregunta: ¿qué es el derecho? También el profano —más aún, como se verá, el profano que el técnico— advierte inmediatamente que la palabra adquiere, según las diversas locuciones de que forma parte, dos significados distintos: si hablo del derecho romano o del derecho civil vigente o del derecho de propiedad como institución, la palabra derecho contiene la representación de un conjunto de disposiciones que imprimen determinadas direcciones a la actividad humana o la encierran dentro de ciertos límites; en cambio, si hablo de mi derecho de crédito o

de mi derecho de propiedad, pienso en un poder que extiende y acrecienta mi campo de acción sobre personas y cosas. Para las locuciones de la primera especie se acostumbra decir que la palabra *derecho* está usada en sentido objetivo; para las de la segunda, en sentido subjetivo.

Si nos proponemos precisar el concepto de derecho en sentido objetivo, observamos en seguida que la actividad humana está regida, en primer lugar, por un indefinido número de estímulos que la impulsan, bajo la sanción del placer o del dolor, hacia este o aquel bien (real o supuesto), y además por un multiforme aparato de normas; establecidas éstas, en su parte más selecta, por nuestra misma conciencia o tan plenamente asimiladas por ella que pueden sentirse como autónomas, o bien impuestas desde afuera y sentidas, por lo tanto, como heterónomas, como un constreñimiento que se sufre por el temor de un mal mayor que amenaza a quien no las cumpla. Si tengo un pedazo de pan y un hambriento me lo pide, una norma que no necesita expresarse para ser sentida, me impone el deber de compartirlo con él. Si quiero arrojar a la basura el pan que me sobra después de haber satisfecho mi necesidad (y eventualmente la ajena), una norma diversa me prohíbe despreciar ese *panem nostrum quotidianum*, y es ya una norma menos íntima, que depende de la arbitraria interpretación de una fórmula, más que de una necesidad de razón. Pero si el necesitado que me pide el pan es mi hermano según la ley, a la precitada norma autónoma se le agrega —para imponerme el reparto— otra exterior, heterónoma, la que se encarga de constreñirme eventualmente a la obediencia o, si es necesario, de realizar el reparto contra mi voluntad. En fin, si voy distribuyendo aquel pan, por mero acto de cortesía, entre los convidados de un banquete, y estoy tentado de excluir de la distribución a determinada persona, todavía otra norma (la menos íntima y la más heterónoma que pueda pensarse, pero siempre una norma) me prohíbe este acto de descortesía.

Hemos ejemplificado así los tipos fundamentales de normas (*morales, religiosas, jurídicas y de cortesía*), en un orden que corresponde a su diverso valor ético (no decimos a la apreciación social, que podría también ser exactamente la inversa); pero no debe descuidarse el fenómeno de la frecuente recepción de las normas de cada sistema en uno o más de los otros: así, hemos visto que la norma por la que estoy obligado a alimentar a mi hermano ne-

cesitado, es antes moral que jurídica, y también la religión hace propia la regla de dar de comer a los hambrientos, y la obligación del saludo (que normalmente es de mera cortesía) se convierte en obligación jurídica para los militares.

Entre las diversas categorías de normas, las del derecho se distinguen de las demás, sea por el fin a que tienden, sea por la naturaleza del constreñimiento que las acompaña. Fin de toda norma jurídica es la conservación y el perfeccionamiento de una sociedad humana, es decir, de una comunidad organizada para una duración indefinida y para la persecución de fines comunes; normalmente, en el mundo civilizado, la sociedad a que el derecho se refiere es el Estado, y no es éste el lugar para plantearse el problema de si existen a su lado otras sociedades que pueden ser objeto de ordenamiento jurídico¹.

En cambio, no es característica exclusiva de las normas jurídicas la sanción, es decir, la conminación de un mal o de la pérdida de un bien para el trasgresor; pero es propio del derecho que la sanción sea conminada a través de una norma secundaria, dirigida a las mismas personas a que se refiere la norma primaria o a otras personas; y es propia de la sociedad organizada para la cual se ha establecido el derecho, la posibilidad de crear órganos y expedientes que permitan hacer lo más cierta posible la aplicación de la sanción misma².

Mucho más difícil es la definición del derecho en sentido subjetivo: no tanto por la gravedad de las disensiones acerca de la

¹ Cfr. sobre el problema: ROMANO, *L'ordinamento giuridico* (1915; 2ª ed., Firenze, 1946), con el cual se puede convenir en reconocer carácter jurídico también a las normas del derecho eclesiástico internacional, pero sólo cuando y en cuanto la Iglesia o la *societas gentium* tengan sobre los particulares coparticipes un poder que los una y los domine.

² Es cierto que algunas normas (y precisamente las que parecen estar en la base del sistema jurídico) se hallan formalmente desprovistas de sanción: en Roma se pudo discutir largamente si fué legal la propuesta de Tiberio Graco, de que el tribuno que interpuso el veto contra su ley agraria fuese depuesto (*Storia*, 5ª ed., p. 190); pero una vez aceptada la propuesta, y pronunciada por plebiscito la deposición, ninguna autoridad habría podido hacer que Octavio volviese al tribunado, ni que Tiberio fuese sometido a una pena. La violación de semejantes normas es acto revolucionario, y su sanción está en las ulteriores violaciones (en sentido opuesto) que son suscitadas por la ocurrida trasgresión a la convención sobre la cual se funda la sociedad; o bien en el comienzo de la formación de un orden nuevo que sustituye al antiguo, que ya no corresponde a las exigencias de la comunidad.